

1500643-82.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... que os narcóticos se destinavam ao tráfico. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Repise-se que o réu confessou o narcotráfico (fls. 04), o que corrobora a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500643-82.2021.8.26.0571 - Controle 2021/000637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS HENRIQUE DE ALMEIDA GABRIEL DE SOUZA

Data da Audiência:

30/03/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Mateus Henrique de Almeida Gabriel de Souza. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Gustavo Henrique Gomes e Maycon Douglas Cassemiro arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 14h30, na Rua Mario Moreira, nº 475, Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Itapetininga, trazia consigo e guardava, para comercialização a terceiros, 09 (nove) microtubos de cocaína, com peso líquido de 1,42g (um grama e quarenta e dois centigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08, auto de constatação provisória de fls. 11/13 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 70/72. O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 105/106). A denúncia foi recebida em 18/11/2021 (fls. 107/108) e o acusado foi citado (fls. 119). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que

a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), auto de constatação (fls. 11/13) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 70/72). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu disse que empreendeu fuga quando avistou a polícia. Falou que dispensou a droga e acabou abordado. Contou que os policiais encontraram o entorpecente dispensado, tratando-se de 09 porções de "cocaína". Afirmou que vendia cada porção por R\$ 10,00 (fls. 04). Interrogado em Juízo, o acusado voltou atrás. Segundo ele, assim agiu para que outro "rapaz" não fosse preso. Na verdade, segundo ele, a droga era destinada ao uso pessoal. A prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas, momento em que avistaram o denunciado. Ocorre que, ao perceber a presença da viatura, MATEUS prontamente saiu correndo, entrou em um matagal e dispensou algo ao chão, sendo que os policiais saíram ao encalço dele. Então, os policiais abordaram o denunciado e, em revista pessoal, com ele encontraram o valor de R\$ 30,00 (trinta reais). Ato contínuo, ao analisarem o que MATEUS havia dispensado antes da abordagem, os policiais encontraram 09 (nove) pinos de cocaína. Indagado, o denunciado confirmou que estava comercializando as porções de droga por R\$ 10,00 (dez reais) cada uma. MATEUS foi preso em flagrante delito. Pois bem. Agora, o policial Gustavo afirmou que o réu foi abordado em conhecido ponto de drogas. Segundo ele, o réu foi avistado, ao lado de um córrego, e logo saiu correndo. Houve perseguição e ele se entregou. Nesse exato instante, o acusado jogou uma sacola que estava em suas mãos. Em revista pessoal foi constatado que o réu trazia consigo R\$ 30,00. A sacolinha arremessada abarcava a droga descrita na denúncia. O réu admitiu o tráfico e deu detalhes de seu "negócio". O policial Douglas referendou as palavras do seu colega. Pontou que o acusado admitiu o crime e informou que, a pouco, tinha vendido doses de entorpecente para um caminhoneiro. Como se vê, toda a dinâmica da abordagem demonstra que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes. As circunstâncias da apreensão das drogas, tais como o fato de MATEUS encontrar-se em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, a conduta do denunciado de prontamente correr e dispensar as drogas ao chão ao notar a presença da viatura, a natureza extremamente nociva e viciosa, bem como a forma de acondicionamento das drogas, já em porções individuais, prontas para a venda, a quantia em dinheiro, além da confissão informal do denunciado, não deixam dúvidas de que os narcóticos se destinavam ao tráfico. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que nada está a indicar que as testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Repise-se que o réu confessou o narcotráfico (fls. 04), o que corrobora a versão incriminatória. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta Maus antecedentes e é primário (fls. 22/25). Nada impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. O regime inicial de cumprimento de pena poderá ser o aberto e se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. I- DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11343/06: A acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade entorpecentes e na suposta confissão extrajudicial do réu, a fim de imputar-lhe a conduta descrita no art. 33 da Lei de Drogas. No entanto, além de a confissão não ser sido ratificada em juízo, é certo que o acusado não foi preso mantendo contato com pessoas, não possuía apetrechos para o tráfico e nem grandes valores em dinheiro, mas apenas - de acordo com os

depoimentos – na posse de pequena quantidade de entorpecente, de modo que a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do *in dubio pro reo*, que determinam que se presume que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Ainda, o fato de as substâncias estarem embaladas individualmente nada indica: se alguém vende a droga fracionada, alguém a compra também fracionada, de modo não há como inferir a mercancia apenas em razão desta circunstância. Como o réu não foi visto em atitude típica de mercancia, todas as circunstâncias indicam se tratar de hipótese de uso. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais.

II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, *verbis*: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal; b) Na segunda fase de dosimetria da pena deverá ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, caso seja ela valorada pela sentença condenatória; c) seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixado regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos, ante a primariedade do réu e em conformidade com os arts. 33, 44 e 59 do Código Penal; d) a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. MATEUS HENRIQUE DE ALMEIDA GABRIEL DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 14 h e 30 min, na Rua Mario Moreira, n. 475, Jardim Bela Vista, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para

fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nove microtubos contendo "cocaína", com peso de 1,42 gramas. Notificado, fls. 101, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 105/106. A denúncia foi recebida, fls. 107/108, e o Réu, citado, fls. 119. Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas presentes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 06/07, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 08, no Laudo de Constatação, fls. 11/13, bem como no Exame químico-toxicológico n. 137.295/2021, fls. 70/72, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Gustavo Henrique Gomes e Maycon Douglas Cassemiro, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento em local conhecido pela venda de drogas quando se depararam com o Acusado, também conhecido dos policiais, o qual, ao ver a viatura, saiu correndo, então os policiais foram atrás e o Acusado entrou em um matagal e dispensou algo; após ser alcançado, os policiais constataram que ele havia dispensado um saco plástico contendo 09 porções de "cocaína". O Acusado admitiu a venda de drogas. Ele estava sozinho. Mateus Henrique de Almeida, Réu, ao ser interrogado, disse que as drogas eram suas, mas para uso pessoal. Somente afirmou que eram para venda por pressão dos policiais, os quais lhe disseram que levariam outra pessoa presa se não admitisse o tráfico. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, os policiais estavam em patrulhamento quando se depararam com o Réu, o qual trazia consigo um saco contendo 9 porções de "cocaína" e ele, ao ver a viatura, fugiu, entrou em uma trilha e depois dispensou o objeto. A quantidade, a forma de separação e a quantidade de porções, além do local, conhecido ponto de venda de entorpecentes, demonstram claramente a finalidade mercantil, mesmo porque não é crível que estivesse em via pública, naquele horário, com outro objetivo além da venda de drogas. Ademais, havia dinheiro, fruto de vendas pretéritas, o que se infere das circunstâncias e da ausência de demonstração de ocupação lícita. O Réu negou o comércio ilícito e disse que somente o admitiu por pressão dos policiais, todavia sua versão restou isolada e inverossímil, pois não é crível que as testemunhas tivessem intenção de prejudica-lo e, ademais, na Delegacia de Polícia o Acusado confessou o tráfico de entorpecentes, fls. 04. Os policiais deram testemunhos firmes, coerentes, e descreveram de forma isenta os fatos como ocorreram. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo substâncias entorpecentes, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso.

Art. 61 e art. 65, do CP: O Réu é menor de 21 anos, logo faz jus à atenuante. Todavia, na segunda etapa, as atenuantes não tem o condão de minorar a reprimenda aquém do piso legal. Esse é o entendimento consubstanciado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". - Art. 68, do CP: Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao "pequeno traficante", de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Conforme se verifica às fls. 25, Certidão do Cartório Distribuidor de Ações da Infância e da Juventude, o Réu possui cinco registros, o que permite afirmar, com certeza, que vem se dedicando a atividades criminosas, situação incompatível com a concessão do redutor, conforme decidiu o Colendo STJ, RHC 63.855, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 11.05.2016. No mesmo sentido HC 420720 / SP HABEAS CORPUS 2017/0266511-7 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 10/04/2018. Ementa: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFINA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO EM ATO INFRACIONAL RELATIVO A TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. LEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) V - Nos termos do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. VI - Embora atos infracionais não configurem maus antecedentes ou reincidência, a prática reiterada pelo paciente de condutas relativas ao tráfico de drogas, inclusive com a procedência de uma representação (condenação), impede seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, considerando que tais elementos demonstram que o agente se dedica às atividades criminosas. Nestes termos afasto a causa de diminuição de pena. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: Considerando-se a quantidade e a natureza dos entorpecentes e a pena fixada, o regime será o inicial semiaberto. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Ausentes os requisitos, à vista da pena fixada. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar MATEUS HENRIQUE DE ALMEIDA GABRIEL DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Sem condenação nas custas. Decreto da perda dos valores apreendidos. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital

- sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 30 de março de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA